

1500887-55.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 15/03/2022

... passar pela casa da vizinha.

Sendo o tráfico de drogas um crime permanente, a existência de fundadas suspeitas sobre a prática do crime no domicílio autoriza a entrada forçada em domicílio por conta do flagrante, como autoriza a CF:

Habeas Corpus - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico - Pretendido reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Cachoeira Paulista-SP - cep 12630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500887-55.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500887-55.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2277825/2021 - DEL.POL.LORENA, 20769763 - DEL.POL.LORENA, 920/21/204 -

DEL.POL.LORENA, 2277825 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA, 920/21/204 -

DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia em face de JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS pela suposta prática da conduta prevista no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e no artigo 29, parágrafo 1º, inciso III da Lei nº 9.605/98, na forma do artigo 69 do Código Penal. De acordo com a denúncia: no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 13h30, na Rua José Índio do Brasil, nº 175, Centro, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS, vulgo "Jorginho", mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 01 (uma) bolsa contendo 1.658,7 gramas de cocaína pulverizada e 07 (sete) emendorfs da mesma substância, com massa bruta de 12,6

gramas; substância que causa dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/13 e laudo de constatação de fls. 75/77. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supramencionadas, guardava e mantinha em cativeiro, espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

As fls. 100/104 houve homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva.

As fls. 79/81 e fls. 210/212, foram juntados os laudos de constatação, evidenciando a presença de COCAÍNA.

As fls. 227/235, o Réu apresentou resposta à acusação.

Em 09 de dezembro de 2021, houve o recebimento da denúncia (fls.251/253).

As fls.251/253, foi negada a absolvição sumária e designou-se audiência de instrução.

Em 04 e 25/02/2022, foi realizada audiência de instrução.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a materialidade e a autoria estão comprovadas, quanto a ambas as imputações; os depoimentos policiais devem ser considerados; o Réu confessou; o Réu deve ser condenado quanto aos dois crimes; a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas na dosimetria; o Réu é reincidente; não deve ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º; o regime inicial deve ser o fechado; a prisão preventiva deve ser mantida.

Já a defesa, em alegações finais, defendeu que: houve violação de domicílio; o dinheiro encontrado não é produto de crime; o Réu deve ser absolvido.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1. Da alegação de violação de domicílio, da prova ilícita e da descoberta inevitável

O art. 157, caput, do CPP estabelece a inadmissibilidade das provas ilícitas:

Art. 157, caput. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

O art. 5º, XI, da CF estabelece que, sem autorização do morador, só é possível entrar de forma forçada no domicílio em 4 hipóteses: a) em flagrante delito (mesmo que sem autorização judicial); b) desastre (mesmo que sem autorização judicial); c) para prestar socorro (mesmo que sem autorização judicial); d) após ordem judicial escrita, durante o dia:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

No caso concreto, é possível reconhecer a ilicitude quanto ao ingresso na casa da vizinha (MARIA ELISABETE DA SILVA), meio pelo qual os policiais entraram na residência do Réu, uma vez que, segundo a prova colhida, a autorização para ingresso teria se dado a partir de informações enganosas de que alguém teria invadido o quintal de MARIA ELISABETE.

Ouvida em Juízo, a testemunha ZAQUEU SIQUEIRA AZARIAS afirmou que: estava com o parceiro NILTON em Lorena, e abordou alguns usuários de drogas; esses usuários falaram que as drogas eram abastecidos por JORGINHO, que morava em Cachoeira Paulista; foram para Cachoeira Paulista e pediram ajuda policial; cercaram a casa do Réu; pediram para a vizinha lateral para ficarem no imóvel dela; o Réu tentou fugir, mas foi alcançado; o Réu não resistiu à prisão; o Réu reconheceu que havia drogas na residência e falou o local; no rancho na frente, encontraram 1.360kg de

cocaína, sacolés etc.; na revista, TATIANA acompanhou e, no guarda roupa, encontraram R\$2.940,00, que o Réu falou que era dinheiro do tráfico; também encontraram 2 pássaros silvestres; o réu falou que eram de estimação; foi conduzido ao DP; o Réu é conhecido dos meios policiais; as informações dão conta de que ele faz parte de organização criminosa; pulou para a casa do Réu quando viu ele se evadir; o portão é fechado; o Réu descobriu que eram os policiais quando eles avisaram que eram da PM; o Réu não tinha nada nas mãos; o Réu assumiu a responsabilidade e livrou a mulher dele; na viatura da testemunha, tinha mais um; foram mais 2 viaturas, cada uma com dois policiais; a esposa do Réu estava de calça jeans e blusa; TATIANA já conhecia a testemunha por outras prisões; TATIANA acompanhou o encontro dos entorpecentes; não sabia que o Réu é revendedor da AVON e afins; as notas estavam em separadas em bolos de acordo com o valor; o Réu falou que era dinheiro do tráfico; não sabe que TATIANA tem casa de aluguel; os usuários de drogas falaram que TATIANA que levava as drogas; os usuários já falaram que as drogas estavam na casa de JORGE e deram o endereço completo; os policiais não sabiam que ele estava em Cachoeira Paulista; os usuários sabiam e falaram o endereço do tráfico; são informantes da polícia.

Ouvida em Juízo, a testemunha ISANARA LÍDIA DA SILVA afirmou que: nesse dia, foi fazer uma entrevista na pousada Santa Helena; avistou uma viatura vindo 3 policiais (uma policial feminina, um grisalho e um mais forte); um policial começou a bater e afirmou para a moradora que alguém tinha entrado no quintal; entraram no quintal desse imóvel e depois saíram do imóvel do lado com o Réu preso; TATIANA saiu falando que tinham levado o marido dela; pararam na casa do lado direito, na casa da senhora; JORGE saiu da casa em frente à pousada; a pousada é do outro lado da rua, mas conseguiu ouvir.

Ouvida em Juízo, a testemunha MARIA ELISABETE DA SILVA afirmou que: não tinha muita amizade com o Réu e a sua mulher; nesse dia, o interfone tocou e foi abrir o portão; era um policial pedindo para entrar, dizendo que havia uma pessoa no quintal da casa dela (testemunha); por isso, deixou o policial entrar; ficou tudo quieto; depois de um tempo, voltou um policial agradecendo por ter deixado entrar e dizendo que foi tudo resolvido e que o problema era no quintal vizinho; não ficou sabendo de nada; quando foi por volta de 22h30 da noite, a esposa de JORGE entrou em contato e pedindo para a testemunha ir depor; acabou não indo na delegacia; não conhece o Réu; o policial não falou o nome e disse que a pessoa estava no quintal da casa dela; não viu os policiais pularem para a casa do lado.

Assim, o ingresso na residência da vizinha se deu após consentimento viciado (a vizinha teria sido enganada), o que caracteriza ato ilícito pelas autoridades públicas.

Fixada a ilicitude de tal prova, é preciso analisar a extensão dos efeitos da decretação da nulidade.

O art. 157, § 1º, do CPP consagra a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual a ilicitude de uma prova se estende àquelas que derivem dela, isto é, guardem nexos com a prova ilícita:

Art. 157, § 1º São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

No entanto, o próprio legislador estabelece limitações à aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, entre as quais está a descoberta inevitável, mencionada na parte final do art. 157, § 1º, e conceituada no § 2º do dispositivo: Art. 157, § 2º Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. (Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008) (grifos acrescidos)

Sobre a descoberta inevitável / fonte hipotética independente, vale conferir a doutrina:

“b) Descoberta inevitável ou exceção da fonte hipotética independente: se a prova,

que circunstancialmente decorre da prova ilícita, seria conseguida de qualquer maneira, por atos de investigação válidos, ela será aproveitada, eliminando-se a contaminação. A inevitabilidade da descoberta leva ao reconhecimento de que não houve um proveito real, com a violação legal. (...) Na descoberta inevitável, o nexo existe, mas não é decisivo, pois a prova derivada, mesmo que a ilicitude não se operasse, ainda assim seria produzida dentro da lei" (TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 11ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 629) (grifos acrescidos)

No caso concreto, a apuração de que o Réu guardava drogas em sua residência era inevitável, uma vez que os policiais já tinham informações sobre tal fato (que foi confirmado em Juízo pelo Réu) e poderiam ingressar diretamente na residência do acusado, sem passar pela casa da vizinha.

Sendo o tráfico de drogas um crime permanente, a existência de fundadas suspeitas sobre a prática do crime no domicílio autoriza a entrada forçada em domicílio por conta do flagrante, como autoriza a CF:

Habeas Corpus - Tráfico de drogas e Associação para o tráfico - Pretendido reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante ou revogação da custódia preventiva decretada - Não acolhimento. Ingresso domiciliar justificado pelas circunstâncias do fato - Informações prévias a respeito da ocorrência de tráfico de drogas no endereço indicado - Crime permanente - Estado flagrancial bem delineado - Violação de domicílio não configurada - Controle judicial do flagrante realizado pela autoridade coatora - Prisão preventiva decretada - Segregação baseada em novo título - Precedentes. Prisão preventiva - Decisão fundamentada - Presença do "fumus commissi delicti" e do "periculum libertatis" (art. 312, "caput", CPP) - Infração penal que autoriza o decreto da custódia cautelar (art. 313, I, CPP) - Diversidade de espécies e quantidade expressiva de drogas, a indicar a gravidade concreta dos fatos - Custódia cautelar necessária para garantir a ordem pública - Condições favoráveis do agente (como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita) insuficientes para autorizar a liberdade provisória, quando a manutenção da custódia cautelar é recomendada por outros elementos - Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2240212-16.2021.8.26.0000; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021) (grifos acrescidos)

Apelação criminal - Tráfico de drogas e Corrupção ativa- Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Réu absolvido da imputação de infração ao artigo 333, caput, do Código Penal. Recurso do Ministério Público - Requerimento de condenação do acusado pelo delito de corrupção ativa, eis que suficientemente comprovado nos autos. Recurso defensivo - Pleitos preliminares de reconhecimento de nulidade por violação de domicílio e em razão do cerceamento de defesa. Alegação de que houve abuso de autoridade dos Policiais Militares. No mérito, requer-se a absolvição por insuficiência probatória. Preliminares rejeitadas- Busca pessoal realizada no réu em razão de sua atitude suspeita quando avistou a viatura policial - Inexistência de abuso de autoridade. Localizadas drogas em poder do acusado, que apontou um imóvel onde era armazenado o restante do entorpecente. Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto, sendo que a própria Constituição Federal autoriza o ingresso, dentre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito ou mediante consentimento do morador - No caso dos autos, os policiais militares afirmaram que o próprio réu apontou o imóvel como sendo local de armazenamento de entorpecentes - Ademais, o delito de tráfico de drogas que, por ser delito permanente, tem a sua consumação protraída no tempo, permitindo a prisão em flagrante a qualquer momento, e por qualquer pessoa. Fundadas razões que justificaram a atuação policial. Inexistência de cerceamento da Defesa. Magistrado que, em sua discricionariedade, pode indeferir provas que reputar impertinentes. Decisão fundamentada. Materialidade e autoria comprovadas - Prisão em flagrante delito - apreensão de 1,278kg de maconha, dividida em 316 porções; 253,0g de Crack, dividido em 365 porções, e 1,246kg de Cocaína, dividida 964 porções. Policiais

Militares Rodoviários que abordaram o acusado, que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura, quando transitava na Rodovia. Apreendidas drogas, dinheiro e celular com o acusado. Réu que, ao notar que seria preso em flagrante delito, ofereceu aos Policiais drogas e dinheiro, indicando imóvel onde armazenava mais entorpecentes, para que, assim, os Agentes Públicos não o autuassem em flagrante delito. Palavra firme dos Policiais, merecendo credibilidade. De rigor a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas e condenação pelo delito de corrupção ativa. Dosimetria da pena - Tráfico de Drogas - Penas-base justificadamente fixadas acima do mínimo, em razão da quantidade e diversidade dos entorpecentes, além dos maus antecedentes do réu. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência. Na derradeira etapa, incabível a aplicação do redutor de pena, diante da recidiva e das circunstâncias fáticas, que denotam dedicação à atividade criminosa. Corrupção ativa - Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão do registro de maus antecedentes. Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência. Sem alterações na derradeira etapa. Concurso material de crimes - penas aplicadas de forma cumulada. Regime inicial fechado mantido, eis que bem justificado e em virtude das circunstâncias fáticas. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Circunstâncias do caso concreto que não recomendam a substituição - Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. Matéria preliminar afastada. Recurso da Defesa improvido. Recurso Ministerial provido, para condenar o réu também pelo delito de corrupção ativa, nos termos deste voto. (TJSP; Apelação Criminal 0003181-44.2020.8.26.0281; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021) (grifos acrescidos)

Assim, por mais que o ingresso pela casa da vizinha tenha sido ilícito, a descoberta das drogas era inevitável, já que os agentes estavam autorizados a ingressar diretamente no imóvel do Réu (inclusive com o uso de força). Aplicando tais considerações ao caso concreto, é possível limitar a ilicitude quanto à violação do domicílio da vizinha e aproveitar a apreensão de drogas na casa do Réu como prova lícita.

II.2 Do crime do art. 33 da Lei de Drogas

Da autoria e da materialidade

Cuidam os autos de ação penal pública que visa apurar a suposta prática do crime de tráfico de drogas na modalidade guardar e ter em depósito.

Inexistindo questões preliminares e/ou prejudiciais capazes de inviabilizar a análise do mérito da causa, ou mesmo nulidades que possam macular os atos e os processos como um todo, as questões trazidas a juízo merecem um provimento jurisdicional de cunho material.

O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Na situação ora em apreço, consigne-se, desde já, que a despeito das alegações da defesa técnica, as provas constantes dos autos são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Com efeito, o auto de exibição e apreensão de fls. 15/17 demonstra que foram apreendidos na posse do Réu: a) R\$2.940,00 em espécie; b) 700 sacolés vazios; c) 1.600g de cocaína em uma sacola; d) 7 pinos de cocaína.

Anote-se que, conforme conclusões do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fl. 79/81, bem como do laudo pericial de exame químico-toxicológico de fls. 210/212 constatou que são substâncias entorpecentes as matérias apreendidas (art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Trata-se precisamente de cocaína no total de 168,29g de massa líquida (fls. 79/81). Referidas provas demonstram, além de qualquer dúvida razoável, a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos

autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS foi o autor do crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Ouvida em Juízo, a testemunha ZAQUEU SIQUEIRA AZARIAS afirmou que: estava com o parceiro NILTON em Lorena, e abordou alguns usuários de drogas; esses usuários falaram que as drogas eram abastecidas por JORGINHO, que morava em Cachoeira Paulista; foram para Cachoeira Paulista e pediram ajuda policial; cercaram a casa do Réu; pediram para a vizinha lateral para ficarem no imóvel dela; o Réu tentou fugir, mas foi alcançado; o Réu não resistiu à prisão; o Réu reconheceu que havia drogas na residência e falou o local; no rancho na frente, encontraram 1.360g de cocaína, sacolés etc.; na revista, TATIANA acompanhou e, no guarda roupa, encontraram R\$2.940,00, que o Réu falou que era dinheiro do tráfico; também encontraram 2 pássaros silvestres; o réu falou que eram de estimação; foi conduzido ao DP; o Réu é conhecido nos meios policiais; as informações dão conta de que ele faz parte de organização criminosa; pulou para a casa do Réu quando viu ele se evadir; o portão é fechado; o Réu descobriu que eram os policiais quando eles avisaram que eram da PM; o Réu não tinha nada nas mãos; o Réu assumiu a responsabilidade e livrou a mulher dele; na viatura da testemunha, tinha mais um; foram mais 2 viaturas, cada uma com dois policiais; a esposa do Réu estava de calça jeans e blusa; TATIANA já conhecia a testemunha por outras prisões; TATIANA acompanhou o encontro dos entorpecentes; não sabia que o Réu é revendedor da AVON e afins; as notas estavam em separadas em bolos de acordo com o valor; o Réu falou que era dinheiro do tráfico; não sabe que TATIANA tem casa de aluguel; os usuários de drogas falaram que TATIANA que levava as drogas; os usuários já falaram que as drogas estavam na casa de JORGE e deram o endereço completo; os policiais não sabiam que ele estava em Cachoeira Paulista; os usuários sabiam e falaram o endereço do tráfico; são informantes da polícia.

Ouvida em Juízo, a informante TATIANA ESPÍNDOLA DAMÁSIO DOS SANTOS afirmou que: recebe alugueis; estavam em casa e estavam fazendo comida; a cachorra começou a latir; o policial NILTON deu um mata leão em JORGE, que desmaiou; perguntou se poderia colocar roupa (não deixaram); os policiais começaram a andar na casa; ZAQUEU gritou bingo e falou para ela sair do quarto (quando encontrou o dinheiro); na parte de fora, mostraram uma sacola com drogas; negou que houvesse drogas na casa; os policiais prenderam em flagrante o Réu; lá fora, deparou-se com a moça do outro lado da rua; a moça do outro lado da rua perguntou o que estava acontecendo; ISANARA viu que os policiais entraram na casa da vizinha (BETE); havia uma policial feminina; a pousada é em frente à casa; daria para escutar a conversa entre os policiais e BETE, mesmo do outro lado da rua; BETE só respondeu no dia seguinte; o relacionamento com o Réu era de 1 ano e 6 meses; moravam em Lorena e foram para Cachoeira Paulista; ambos faziam cachorro quente; em Lorena, o Réu mexia com pintura; o Réu era usuário de crack; sabia que o Réu tinha sido preso; o Réu foi solto em maio e ela conheceu ele em junho; estavam morando em Cachoeira Paulista há uns 6 ou 7 meses; pagavam R\$750,00 de aluguel; no carrinho de hot dog, faziam R\$180,00 por dia; o Réu também vendia cosméticos; as casas de aluguel ficam em Lorena; alugam 4 imóveis e recebem, por mês, R\$2.500,00; tem os contratos de todos os alugueis.

Em seu interrogatório, o Réu JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS afirmou que: nesse dia, estava em casa com a esposa e os filhos dela; estava no quarto e a esposa estava fazendo comida; escutou a cachorra latindo dentro de casa; pegou o prato e olhou para a porta da sala; a cachorra continuava latindo; foi com o prato na mão para ver para quem a cachorra estava latindo; na porta da sala, se deparou com o policial NILTON que deu uma gravata e apagou o Réu; não sabe como ele entrou dentro da casa; quando acordou, estava na sala com os pés algemados com os policiais perguntando onde estava a droga; reconheceu que a droga estava do lado, numa sacola (maconha); os policiais disseram que estavam atrás de pedra e de maconha; recebeu pó para guardar, em 2 dias; perguntou como o policial achou a casa, que disse que "caguetaram"; foi preso; passaram uns dias e soube como entraram na casa; em nenhum momento, escutou policial chamando na porta da casa; não sabe quanto era de droga; tinham passarinhos em casa, de estimação; na hora da entrada, a esposa estava só de

lingerie; a esposa não acompanhou as buscas dentro de casa; tinha policial feminina na abordagem.

Com efeito, as provas colhidas durante a instrução processual são bastantes a fundamentar um juízo condenatório.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato.

(TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos.

Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Os depoimentos colhidos foram coerentes entre si, convergindo quanto ao fato de que o Réu mantinha as drogas apreendidas em sua residência.

Deve-se ressaltar que, diante da multiplicidade de condutas previstas no art. 33,

caput, da Lei de Drogas, não é necessária a comprovação cabal da mercancia, bastando que haja prova da adequação da conduta a qualquer um dos verbos previstos no tipo penal:

Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Recurso defensivo buscando a desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, a redução da pena, afastando-se o aumento de pena em razão de condenação sem trânsito em julgado para o réu, e mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 8,98g de cocaína, na forma de crack – Réu que negou a prática delitiva – negativa que não prospera – Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante do réu, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas. Relataram que, após informação de que o réu retornaria da cidade de Dracena, onde foi comprar drogas para posterior comercialização no Município de Ouro Verde, deslocaram-se até a Rodoviária e aguardaram o retorno dele. Visualizaram o réu descer do ônibus e ele, ao perceber a presença policial, tentou se desfazer da droga. Realizada a abordagem e indagado, o acusado declarou que a droga destinava-se ao seu consumo próprio. A droga foi localizada, e constataram se tratar de uma porção de crack, que não estava fracionada, e não poderia ser consumida naquele estado, sem antes fracioná-la. Réu que é conhecido pela alcunha 'Boliviano', e pela prática de tráfico de drogas, com prisão anterior pela prática do mesmo delito. Droga apreendida com o réu que renderia entre trinta a quarenta porções de crack – Tráfico de drogas consumado – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – condenação de rigor, nos termos da denúncia. Dosimetria – Pena-base fundamentadamente exasperada – Sem alteração na segunda e terceira fases. Não cabimento do redutor de pena, por falta de amparo legal Não cabimento de penas restritivas de direitos, por falta de amparo legal Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado no caso concreto. Recurso da Defesa improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0001325-64.2018.8.26.0168; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 26/04/2019) (grifos acrescidos)

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou os fatos descritos na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Conforme a teoria da indiciabilidade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto a culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o Réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que o Réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu JORGE

LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.343/06: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, é inerente ao tipo penal; b) Antecedentes: trata-se de acusado com maus antecedentes criminais (condenações nos processos de n. 0000337-39.2013.8.26.0323 (furto) e 0002336-95.2011,8.26.0323 (tráfico de drogas), conforme certidão de fls. 90/93), razão pela qual poderá ser considerada negativa; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida dos acusados em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade dos réus, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: trata-se de crime sem vítima determinada, motivo pelo qual tal circunstância será valorada como neutra; i) Natureza e a quantidade da droga: no caso, foi apreendida considerável quantidade de cocaína (168,29g de massa líquida (fls. 79/81)), razão pela qual é possível valorar negativamente essa circunstância.

Desta forma, aplico o acréscimo de 1/3 do intervalo de pena e fixo a pena-base em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias multa.

Na segunda fase, é preciso reconhecer a agravante da reincidência (condenação no processo de n. 000854120.2015.8.26.0156, conforme certidão de fls. 90/93).

Com relação às atenuantes, é possível reconhecer a da confissão, o que permite a compensação com a reincidência.

Por isso, a pena intermediária é fixada em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias multa.

Quanto à terceira-fase, é preciso enfrentar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, que exige a presença de quatro requisitos para a diminuição da pena: a) primariedade do agente; b) bons antecedentes; c) ausência de dedicação a atividades criminosas; d) não integração de organização criminosa.

O STJ entende que a dedicação a atividades criminosas pode ser aferida com base em inquéritos policiais e ações penais em curso, sem que isso represente violação à presunção de inocência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÕES PENAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

- A Terceira Seção, no julgamento do EResp n. 1.413.091/SP, da relatoria do Ministro Félix Fischer, assentou o entendimento de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou de ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

- A Corte local formou o seu convencimento a partir do acervo fático-probatório, a denotar que o tráfico operado não se dava de forma eventual, mas, sim, com

habitualidade, ou seja, que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Com efeito, a forma como se deu a prisão em flagrante (precedida de investigação pela prática de outro delito que resultou em mandado judicial de busca e apreensão domiciliar), a quantidade e a forma de acomodação do material entorpecente apreendido e o fato de o agravante responder a outras ações penais sugerem a sua dedicação às atividades criminosas, impedindo a aplicação do benefício. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.

- Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 684.376/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) (grifos acrescidos)

Já o STF tem precedentes em sentido contrário:

PENA - FIXAÇÃO - ANTECEDENTES - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 - ATIVIDADES CRIMINOSAS - DEDICAÇÃO - PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020) (grifos acrescidos)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PROCEDIMENTOS E/OU PROCESSOS CRIMINAIS SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA APLICAR A MINORANTE FUNDAMENTADAMENTE E RECALCULAR A DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em "investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional" (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. II - A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 144309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 26-11-2018 PUBLIC 27-11-2018) (grifos acrescidos)

Como ponto de partida, entendo que, em princípio, inquéritos e ações penais em curso não podem afastar a causa de diminuição de pena.

Por outro lado, há situações em que se pode verificar, mesmo sem o trânsito em julgado, que há dedicação a atividades criminosas: a) prisões em flagrante repetidas em curto espaço de tempo; b) sentença condenatória proferida em outro processo; c) alguma circunstância que deixe claro que, no caso concreto, há efetiva dedicação a atividades criminosas.

No caso concreto, nota-se que o agente é reincidente específico (condenação no processo de n. 0008541-20.2015.8.26.0156, conforme certidão de fls. 90/93), razão pela qual não é possível aplicar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Por isso, não aplico a causa de diminuição de pena e fixo a pena definitiva em 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias multa.

Nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena.

Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do CP, entendo pela aplicação de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pois não há dados sobre a situação econômica do réu.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I) e a suspensão condicional da pena (art. 77).

II.3 Do crime do art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/98

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade do crime do art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/98 restou devidamente comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 8/12), do auto de entrega (fls. 29), das fotos de fls. 36/40 e das provas orais produzidas nos autos.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS foi o autor do crime do art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/98, conforme será devidamente demonstrado a seguir, conforme transcrições acima.

Em primeiro lugar, deve-se destacar que, na ausência de dúvida razoável sobre a parcialidade dos policiais envolvidos na operação, o seu depoimento é um meio idôneo de prova:

Apelação - Furto qualificado tentado - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova oral harmônica e coesa - Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade - Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade - Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial - Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância - Ausência de previsão legal - Afronta ao direito fundamental de propriedade - Cabimento do "furto privilegiado", desde que preenchidos os requisitos legais - Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) - Descabimento - Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 - Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) - Inviabilidade - "Iter criminis" percorrido pelo agente - Proximidade da consumação - Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Reincidência específica - Recurso não provido - Erro material da sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato.

(TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos)

APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Preliminar. Alegação de ausência do laudo de exame de corpo de delito. Crime que deixa vestígios. Nulidade não reconhecida. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Condenação mantida. Dosimetria da pena que, entretanto, comporta reparo. Maus antecedentes descaracterizados. A utilização de condenações pretéritas registradas há mais de quatorze anos em desfavor do condenado contrapõe-se à proposta legislativa que fundamenta o próprio

sistema de penas, não se reputando legítima a delonga de um desvalor social superado pelo réu criminalmente reabilitado. Reincidência descaracterizada. Documento que não traz informação acerca do trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa. Pena reduzida ao mínimo legal. Regime inicial de cumprimento abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Restituição de bens e valores apreendidos. Impossibilidade. Objetos que interessam à persecução penal. Incidência dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal. Sentença reformada em parte.

PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500083-83.2019.8.26.0548; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro: 06/10/2020) (grifos acrescidos)

Além disso, o boletim de ocorrência de fls. 8/12 confirma que houve a apreensão de passarinhos 2 "trinca-ferro" e 1 "coleirinha"

Nessa esteira, o Réu agiu com consciência e vontade, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia, para guardar em cativeiro os pássaros silvestres mencionados, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, razão pela qual praticou a conduta amoldada à previsão típica do art. 29, §1º, III, da Lei 9.605/98.

Em contrapartida, tendo em vista as circunstâncias concretas do delito, ressalta-se que o acusado detinha 2 pássaros da mesma espécie ("trinca ferro") e 1 da espécie "coleirinha", que possuía com animais de estimação, conforme fotos anexadas.

Além disso, as fotos indicam que os animais estavam em boas condições físicas, sem sinais de maus tratos e não há elementos em sentido contrário.

Por fim, ressalte-se que: a) não houve nenhum relato de obstáculos à atuação policial quanto aos animais; b) os animais não são de espécies ameaçadas de extinção de acordo com as Portarias 444 e 445 do Ministério do Meio Ambiente.

Nesse contexto, é preciso lembrar o que o art. 29, §2º, da Lei n. 9.605/98 prevê uma hipótese de perdão judicial quando se tratar de guarda doméstica de animal não ameaçado de extinção, desde que as circunstâncias do caso justifiquem.

Em situações semelhantes, o TJSP reconheceu a possibilidade do perdão judicial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. Art. 29, caput e §1º, III, c.c. § 3º, da Lei nº 9.605/98. Guarda doméstica de 04 pássaros da fauna silvestre. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão do réu corroborada pelos demais elementos.

Comprovada lesão ao ecossistema, colocando em risco o direito constitucional de tutelar sua preservação para as gerações presentes e futuras. Inaplicável a insignificância. Condenação mantida. Concessão do perdão judicial previsto no art. 29, § 2º, da Lei Ambiental. Possibilidade. Espécimes apreendidas que não são consideradas ameaçadas de extinção e que estavam bem tratadas, tanto que foram mantidas em depósito com o apelante. Extinção da punibilidade. Apelo parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Criminal 3002002-92.2013.8.26.0079; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 21/02/2020) (grifos acrescidos)

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PAULO e PATRÍCIA: pretendida absolvição.

Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda, inclusive, as pretendidas desclassificações aos crimes do art. 28 e art. 33, § 2º ou 3º.

MINISTERIAL: alijamento do redutor do § 4º. Plausibilidade. Circunstâncias que demonstraram dedicação às atividades criminosas. Aumento das penas. Modificação do regime ao fechado. Provimento. ASSOCIAÇÃO AO MESMO CRIME. MINISTERIAL: pretendida reversão da improcedência. Impossibilidade. Absolvição bem reconhecida, porque inexistentes elementos a comprovar o respectivo vínculo. Improvimento, com observação. RECEPÇÃO - DEFENSIVO: desejada reforma da condenação.

Impossibilidade. Autoria e materialidade plenamente comprovadas. Penas e regime preservados. Improvimento. CRIME CONTRA A FAUNA - DEFENSIVO: absolvição.

Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Guarda de pássaro

"Coleirinha", em cativeiro, espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, mas, com confirmação do IBAMA, de não estar incluído em qualquer lista de extinção. Ave devidamente cuidada. Perdão judicial bem concedido. Pena não aplicada. Inteligência da Lei nº 9.605/98, art. 29, § 2º. Improvimento, com observação. FURTO SIMPLES - SHIRLENE. Preliminar de nulidade do feito repelida. Improcedência da pretensão punitiva. Descabimento. Prova robusta. Sanções bem fixadas. Modificação ao regime aberto, em caso de reversão da substitutiva. Provimento parcial.

(TJSP; Apelação Criminal 0011116-46.2011.8.26.0445; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Pindamonhangaba - 3ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/09/2015; Data de Registro: 15/09/2015) (grifos acrescidos)

Diante disso, assim, concedo o perdão judicial previsto no art. 29, §2º, da Lei 9.605/98, por não vislumbrar a necessidade da intervenção extrema do Direito Penal na hipótese sob julgamento.

III - DISPOSITIVO

Inicialmente, concedo o perdão judicial e julgo extinta a punibilidade do acusado JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS com relação à imputação do crime do art. 29, §1º, III, da Lei n. 9.605/98, o que faço com fundamento no art. 107, IX, do Código Penal c/c art. 29, §2º, da Lei 9.605/98.

Além disso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o Réu JORGE LUIZ DAMÁSIO DOS SANTOS pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 às penas de 8 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 833 dias-multa no valor individual de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO os sentenciados ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes atribuídos ao réu. O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela reiteração de condutas (certidão de fls. 90/93) e pela